

1524988-74.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... (cem reais). Relatou que estava no tráfico desde maio, para ajudar a mãe a pagar o aluguel, que está desempregada. Aduziu que não conhecia o motorista do Uber.

Em juízo, o réu confessou que estava com as drogas e pretendia vender. Falou que tinha 30 reais consigo, pelo que se lembra. Aduziu que tinha acabado de começar com o tráfico. Explicou que estava passando por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524988-74.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524988-74.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KAIQUE ZEBELIN FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

KAIQUE ZEBELIN FERNANDES (RG: 56718498/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/06 combinado com o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 14 de outubro de 2021, por volta de 10h30, durante período de calamidade pública causado pela pandemia de COVID-19, na Rua Japichaua, altura do número 100, Vila Jacuí, nesta cidade e comarca, teria consigo, para entrega ao consumo de terceiros, a quantia total de 84 (oitenta e quatro) porções contendo 61g (sessenta e um gramas) de cocaína e de 27 (vinte e sete) porções contendo 45,7g (quarenta e cinco gramas e sete decigramas) de tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecido por "maconha", além de 24 (vinte e quatro) porções de substância a ser determinada em laudo definitivo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 04), sendo convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 55/58).

O réu foi citado (fls. 94), apresentando defesa prévia (fls. 97/98) e a denúncia foi recebida (fls. 100).

Durante a primeira audiência de instrução foi ouvida uma testemunha policial. Durante a audiência em continuação foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum; ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, com a fixação do regime fechado.

A Defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão e menoridade como atenuantes e sua compensação integral com a reincidência específica; o afastamento da agravante da calamidade, eis que não configurada; a fixação de regime diverso do fechado; e, por fim, requer a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 09/10 e 11/15); auto de exibição e apreensão (fls. 16/18); laudo de constatação (fls. 38/42); laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 107/110); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O laudo químico-toxicológico definitivo comprova que as drogas apreendidas em posse do acusado eram: 84 (oitenta e quatro) porções contendo 61g (sessenta e um gramas) de cocaína e de 27 (vinte e sete) porções contendo 45,7g (quarenta e cinco gramas e sete decigramas) de tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida por "maconha", além de 24 (vinte e quatro) porções contendo 4,7g (quatro gramas e sete decigramas) de MDMB-4en-PINAC.

As testemunhas policiais Igor Fontes Martins e Raissa de Freitas Ferreira, em sede policial, declararam que estavam cumprindo uma fiscalização de rotina, quando se depararam com o automóvel FIAT/UNO de placas PYP922, em cuja direção encontrava-se Reginaldo Trajano da Silva, que, no ato da abordagem, informou que estava trabalhando para o aplicativo UBER. Informaram que no banco traseiro estava Kaique Zebelin Fernandes, o qual estava com uma bolsa no colo, e que, percebendo a ação dos policiais, tentou esconder o objeto e demonstrou nervosismo. Relataram que deram ordem para que Kaique desembarcasse do veículo e, após revista pessoal feita, foi encontrada uma bolsa contendo invólucros com substâncias na cor branca, aparentando ser cocaína, e invólucros com substância esverdeada, aparentando ser maconha, além de R\$60,00 (sessenta reais) em espécie.

Em juízo, o policial Igor narrou que estava fazendo uma fiscalização de trânsito, o veículo onde o réu estava foi selecionado, e o acusado tentou esconder uma sacola e, nervoso, não soube responder o que tinha dentro, então foi feita uma busca pessoal e foi encontrada uma bolsa com entorpecentes dentro. Falou que o réu confessou que um indivíduo teria entregado as drogas para ele, e estava levando até um local onde seria comercializado. Explicou que o veículo era de aplicativo, Uber, e o réu estava no banco de trás, atrás do banco do passageiro. Disse que a polícia confirmou isso com o motorista, que, apesar de ser da região, disse que não conhecia o réu, e tinha sido chamado via aplicativo. Relatou que não se lembra se o motorista chegou a ver o que tinha dentro da sacola. Respondeu que também foi realizada busca no carro e no motorista, e nada de ilícito foi encontrado.

Em juízo, a policial Raissa narrou que estava fazendo um bloqueio policial e pararam um Uber, momento em que o réu ficou nervoso e, após a busca, foi encontrada droga numa sacola plástica que estava no colo dele. Afirmou que ele teria confessado que estava levando a droga da sua casa até o ponto de tráfico. Confirmou que a abordagem foi aleatória, não havendo informação prévia sobre a droga. Lembra que havia cocaína e maconha.

A testemunha Reginaldo Trajano da Silva, em seu termo de depoimento, em sede policial, declarou que é motorista do aplicativo "99", e foi chamado para realizar uma viagem iniciada na Rua Seis de Dezembro, na Vila Nova União, até a Pizzaria Donatello, que fica na Rua Professor Antônio de Castro Lopes, 1385, no bairro Ermelino Matarazzo, por volta das 10h15 da manhã, por um cliente chamado Leonardo. Relatou que, durante o trajeto, a polícia militar abordou o veículo e encontraram com o passageiro, dentro de uma mochilinha preta, uma quantidade de entorpecentes. Em juízo, a testemunha Reginaldo narrou que pegou o passageiro no bairro Vila Nova

onde eles moram, e o réu estava sendo transportado para a Av. Paranaguá, quando a PM os parou e foi revistar o carro, quando apreenderam entorpecentes, mas ele não sabe a quantidade. Explicou que foi chamado pelo aplicativo 99 e que não conhecia o acusado. Falou que não se lembra bem, por causa do tempo, mas acredita que iria levar o réu na Av. Paranaguá e que a polícia os abordou na Rua Japichaua. Relatou que não viu o réu transportando alguma coisa na mão, que este estava sendo no banco de trás e a droga estava "mais ou menos" com ele. Aduziu que não lembra onde foram apreendidos os entorpecentes. Explicou que os policiais fizeram a revista nele e no réu, e o réu estava com os entorpecentes, mas não viu onde foi localizada. Disse que o réu mesmo confessou que as drogas estavam com ele. Asseverou que as drogas não chegaram a ser mostradas, e estava dentro do carro com o réu. Falou que estava dirigindo e o réu entrou pelo banco de trás.

O acusado, KAIQUE ZEBELIN FERNANDES, em seu interrogatório extrajudicial, em sede policial, declarou que estava saindo de casa e indo para perto da Praça Boturussu, onde funciona a venda de entorpecentes. Disse que estava em um Uber e durante o trajeto encontraram um comando, que mandou parar o veículo e perguntaram o que o interrogando tinha na sacola, que continha maconha, space e pó, além da quantia de R\$100,00 (cem reais). Relatou que estava no tráfico desde maio, para ajudar a mãe a pagar o aluguel, que está desempregada. Aduziu que não conhecia o motorista do Uber.

Em juízo, o réu confessou que estava com as drogas e pretendia vender. Falou que tinha 30 reais consigo, pelo que se lembra. Aduziu que tinha acabado de começar com o tráfico. Explicou que estava passando por problemas financeiros e aceitou fazer o serviço pelo qual receberia 300 reais.

Diante do contexto probatório formado no curso da instrução criminal, a condenação do réu é de rigor, pois a conduta criminosa a ele imputada restou cabalmente comprovada, conforme se passará a expor.

Narram as autoridades policiais que durante atividades ostensivas rotineiras, avistaram e abordaram um veículo cujo condutor trabalhava como motorista de um aplicativo e, com o passageiro, após revista pessoal, foi encontrada uma bolsa contendo certa quantidade de drogas que, depois de laudo definitivo, foram atestadas como maconha, cocaína e MDMB-4en-PINAC.

Após o flagrante, já em sede policial, o réu confessou a prática criminosa em interrogatório extrajudicial e complementou que estava no meio por conta de problemas financeiros familiares. Em juízo, o réu confirmou essa versão.

Ademais, a forma com que as drogas estavam acondicionadas e embaladas, em porções individuais, prontas para a comercialização para terceiros, indica a prática incontestada do delito de tráfico de drogas.

Logo, formou-se uma prova segura de autoria, não havendo se falar em insuficiências ou contradições aptas a beneficiar o acusado.

Portanto, de rigor a condenação do acusado nos termos acima expostos.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixo a pena base do crime de tráfico de entorpecentes no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias multa porque não há elementos que justifiquem seu aumento.

Na segunda fase, em razão da reincidência do acusado, conforme consta nas folhas de antecedentes (fls. 55/58), agravo sua pena em 1/6, compensando-a com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, na forma do artigo 67 do Código Penal.

A agravante constante do artigo 61, II, j, do Código Penal deve ser lida com cuidado, especialmente no que se refere à expressão "ou qualquer calamidade pública". A nítida impressão que se extrai do dispositivo é de que haveria a necessidade de o réu ter alguma facilidade para a prática delitiva em decorrência de certos acontecimentos ("incêndio", "naufrágio", "inundação"). Ou seja, alguém que se aproveitando de situações de debilidade que possivelmente está a vítima num momento de "incêndio", "naufrágio", "inundação", por exemplo, deve ter agravada a pena porque foram as situações indicadas que facilitaram a realização da conduta do agente ou tornaram a vítima vulnerável. Após os exemplos expressados pelo legislador ("incêndio", "naufrágio", "inundação"), vem uma cláusula: "ou qualquer

calamidade pública". Ocorre que o raciocínio teleológico do dispositivo é "ou qualquer calamidade pública" que facilite a conduta do autor e/ou demonstre certa fragilidade da vítima quando da conduta, de modo que somente se ficar comprovado, no caso concreto, que a situação de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6 do Congresso Nacional e Decreto nº 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigor em 20 de março de 2020) decorrente da pandemia (coronavírus disease 19 – COVID 19) facilitou ou demonstrou certa vulnerabilidade da vítima, é que se poderá agravar a pena. Ao revés, estaríamos diante de verdadeira responsabilidade objetiva, o que não se admite quando se estuda a essência do Direito Penal. Então, verifica-se que no caso concreto a situação da pandemia em nada facilitou para a prática da conduta típica ou não ficou demonstrado que a vítima estava numa situação mais vulnerável em decorrência da pandemia. Em realidade, a depender das circunstâncias do caso concreto a situação da pandemia em questão poderia até mesmo configurar uma atenuante inominada (art. 66, CP), desde que também ficasse comprovada a circunstância relevante a justificar a minorante. Pelos motivos acima, afasto a agravante mencionada pelo Ministério Público na peça vestibular. No que tange às causas de aumento e diminuição de pena, não se aplica o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, vez que o acusado ostenta reincidência. Não há causas de aumento.

Então, a pena definitiva será de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso. Apesar da reincidência, que poderia impedir o réu de cumprir pena no regime intermediário (art. 33, § 2º, alínea b, CP), é preciso conjugar referido dispositivo com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º XLVI), viabilizando o regime semiaberto. Verifica-se que, embora a quantidade de droga, fracionada em várias frações, e a variedade seja razoável, a pesagem foi pequena. Além disso, na condenação anterior, o réu foi beneficiado com o cumprimento da pena no regime aberto. Da mesma forma que não pode haver progressão de pena por salto, o mesmo raciocínio estatal deve ser feito em caso de condenação. A resposta estatal deve ser progressiva. Assim, num sistema de atuação progressiva da força estatal, é cabível a fixação do regime semiaberto que seria o próximo esperado para quem repetiu a mesma conduta, desde que outros elementos constantes dos autos assim recomendam como é no presente feito. Ressalte-se que, embora seja uma visão lateral, já que informado pelo próprio réu, o acusado estaria passando por problemas financeiros na família. Assim, numa lógica de sistema, é razoável a fixação do regime intermediário. Ademais, trata-se de pessoa jovem, em relação a quem o Estado deve procurar buscar outros mecanismos para se restabelecer alternativas sociáveis de conduta. É o que se depreende da leitura sistemática de vários preceitos da Lei 12.852/2013 (Estatuto da Juventude), especialmente nos artigos 2º inciso VI, 3º inciso XI e 38 inciso IV. Portando, se a escolha for pela prisionização, portanto, que se faça pelo regime mais brando, especialmente porque o regime fechado deve ser reservado para situações excepcionabilíssimas e concretas e não a partir de considerações abstratas.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos por se tratar de pena superior a quatro anos, bem como em decorrência da reincidência específica. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu KAIQUE ZEBELIN FERNANDES (RG: 56718498/SP) como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida nos termos dos artigos 1º, inciso III e 5º, inciso III, da Constituição Federal, cabendo ao juízo das execuções criminais competente aplicar práticas restaurativas, caso existente Grupo Gestor de Justiça Restaurativa na localidade em que o réu estiver cumprindo pena, nos termos da Resolução 225/2016, respeitados os princípios e regras contidos nesta.

O réu deverá permanecer preso porque presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública (anotando-se que o fato é relativamente recente, além de ser o réu reincidente a indicar que a probabilidade da prática de novos crimes), além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, o

réu respondeu ao processo preso e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União, por se tratar de bem proveniente da prática de tráfico, de acordo com o art. 63 da Lei 11.343/06.

P.I.C

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA